

1500180-45.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não haver apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciar terem os acusados praticado o tráfico ilícito, com auxílio mútuo.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500180-45.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500180-45.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN CARLOS MARTINS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

LUAN CARLOS MARTINS e LUCAS MATHEUS RIBEIRO DE SOUZA, nome social "Yasmine", qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal.

Consta que no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 12h05min, na Rua Italiana Fabrete Oger, 1.439, nesta cidade e comarca, os réus, agindo em concurso e com identidade de propósitos, traziam com eles, para futura entrega a terceiros, setenta e sete porções de "maconha", pesando 387,27g e duzentos e setenta e cinco "eppendorfs" de cocaína, pesando 82,90g, substâncias estas entorpecentes e determinantes de dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Portavam, ainda, os réus, um aparelho celular, bloco de folhas com anotações, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, uma faca, diversos "eppendorfs"

vazios e R\$ 330,00

Narra, ainda, a inicial, terem se associado, os réus, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Policiais militares, em patrulhamento de rotina, abordaram o réu Lucas na via, localizando-se, nas vestes, duas porções de "maconha", dois "eppendorfs" de cocaína, o aparelho celular e R\$ 80,00.

Em seguida, após indicação de Lucas, encontraram, em um poste de energia nas imediações, uma sacola contendo cinquenta e seis porções de "maconha" e seis "eppendorfs" de cocaína.

Na residência dos denunciados, os policiais abordaram Luan, que informou manter relacionamento amoroso com o corréu e apontou existência de tóxicos no local. Efetuadas diligências, localizaram os agentes, em diversos cômodos, o restante dos entorpecentes e do dinheiro, além dos petrechos.

Oferecida a denúncia foram os acusados notificados e apresentaram defesa prévia.

Recebida a denúncia foram os réus citados e se designou audiência de instrução, na qual se ouviram duas testemunhas arroladas pela acusação.

Após, foram interrogados os réus

Em debate, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria dos delitos, requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição dos réus alegando, em suma, serem insuficientes as provas a delinear os crimes.

É o relatório.

DECIDO.

Por óbvio, inexistente violação ilícita do domicílio, pois, conforme narrado pelos policiais, sob o crivo do contraditório, o ingresso na residência decorreu, por primeiro, ante o estado de flagrância, constatado pelo encontro das porções dos entorpecentes durante abordagem inicial a Lucas, e, ao depois, ante autorização, dos réus, que, inclusive, acompanharam toda a diligência de busca.

Em se tratando de delito de tráfico de drogas, enquanto o agente possuir substâncias tóxicas, poderá ser preso em flagrante, tratando-se, pois, de crime permanente, propiciando a violabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.

Assim, em razão do estado de flagrância do denunciado, excepcionada está a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, devendo ser, portanto, afastada a alegação de irregularidade da diligência policial. Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICILIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 3. No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha. 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.035.493/AM, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.06.2022). Afastada a preliminar, passo à análise do mérito.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão acostado aos autos às fls. 23/25, que revela o encontro dos entorpecentes, do dinheiro, do celular, da faca, da balança, do rolo de plástico filme, da folha com anotações e dos "eppendorfs" em tela.

Ainda, no pertinente à materialidade, há o laudo de constatação de fls. 48/51 e o

laudo de exame químico toxicológico de fls. 118/121, concludentes no sentido de se tratar de cocaína e de Tetrahidrocannabinol - THC, as substâncias achadas.

Os petrechos foram vistoriados às fls. 135/140.

Na fase policial, ambos os réus, em congruência, admitiram manter relacionamento amoroso e, por enfrentarem dificuldades financeiras, executavam a traficância.

Não desejou o réu Luan melhor esclarecer os fatos, em Juízo.

Em Juízo, disse o réu Lucas ter recebido todo o tóxico que portava como pagamento por serviços sexuais, não tendo praticado a venda naquela data, somente quinze dias antes.

Contam os policiais terem, em patrulhamento, abordaram o réu Lucas, cujo nome social é "Yasmine", na via, localizando-se, em revista pessoal, duas porções de "maconha", dois "eppendorfs" de cocaína, o celular e R\$ 80,00. Relataram que, em um poste de energia defronte ao local de detenção de Lucas, encontraram uma sacola contendo cinquenta e seis porções de "maconha" e seis "eppendorfs" de cocaína. Detalharam, ainda, a busca efetivada na residência dos denunciados, onde detiveram Luan, que informou manter relacionamento amoroso com o corréu e apontou existência de tóxicos no imóvel, ocasião na qual localizaram, em diversos cômodos, o restante dos entorpecentes e do dinheiro, além dos petrechos. Para tais testemunhas, ambos os denunciados admitiram a prática do comércio ilícito.

Vale lembrar que o fato de policiais que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os agentes incriminar os réus ou forjar os crimes. Neste sentido, vale registrar a seguinte decisão do Eg. Supremo Tribunal Federal: "o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

Urge consignar ser grande a quantidade de drogas apreendidas em comparação à condição financeira dos réus, que não comprovaram relação de emprego, logo, seria imprópria somente a eventual uso, guarda ou transporte, por parte de ambos. Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não haver apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciar terem os acusados praticado o tráfico ilícito, com auxílio mútuo.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação pelos elementos que cercam o agente. Confira-se: "Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues). Ainda sobre o assunto: "Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado" (TJSP Ap. 187.915-3/2 Rel. CRISTIANO KUNTZ - RT 727/478). Por fim: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP "RT"729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito" (TJDF AC

13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

O que importa, no caso, é ter sido o entorpecente localizado com os réus em situação de comercialização, o que acontecia com envolvimento de ambos.

Cabia à defesa, nos termos do art. 156 do Cód. de Proc. Penal, a prova certa de não serem os réus pessoas de convívio notório, o que não aconteceu, muito ao contrário, revelou-se vínculo estreito, pois mantinham relacionamento amoroso.

Por isso, tem-se a destacar estarem as provas testemunhal e técnica em perfeita harmonia, inclusive com a confissão da autoria, que se reveste de caráter absoluto, especialmente porque, repita-se, corroborada pelas demais provas.

A análise conjunta das circunstâncias apresentadas leva à conclusão de terem os réus praticado os ilícitos em testilha, quais sejam, o tráfico de entorpecente e a associação para o tráfico de droga.

Não há dúvida no sentido de dividirem os réus as atribuições para que o tóxico fosse comercializado, ou seja, associados, obtinham, partilhavam, transportavam e guardavam com eles a droga para o comércio.

Emerge das provas apresentadas exercerem os denunciados atividades essenciais para a negociação ilegal, ou seja, havia vínculo associativo entre eles, uma predisposição comum de meios para o crime de tráfico de droga.

Além disso, a quantidade de entorpecente apreendida e a forma de embalagem, somadas às circunstâncias acima analisadas, nos moldes do art. 239 do Cód. de Proc. Penal, levam à dedução de que seria por ambos os réus posta em comércio, até porque, não contam com situação financeira que os permita manter tal quantidade de droga para outro fim.

É possível que façam os réus uso do tóxico, mas a venda é certa, até para garantia do uso.

Além disso, a condição de usuário não afasta a de traficante.

Convencida da responsabilidade penal dos réus, passo a individualizar as penas.

- LUAN CARLOS MARTINS:

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

- art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em obediência ao caput do art. 69 do Cód. Penal, a pena totaliza 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

- LUCAS MATHEUS RIBEIRO DE SOUZA:

- art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

- art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por não ostentar maus antecedentes.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em obediência ao caput do art. 69 do Cód. Penal, a pena totaliza 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão, para ambos os réus, é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei nº 11.464/07).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, para ambos os réus, já se observou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. de Proc. Penal.

O fato de terem os réus respondido encarcerados à instrução do feito não implica, com a prolação desta sentença, na concessão de regime menos gravoso. Neste sentido: "(...) PENA. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ART. 387, § 2º, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.736/12. FIXAÇÃO A SER EFETUADA PONDERANDO-SE CONJUNTAMENTE O QUANTUM DA PENA APLICADA COM AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 33, § 3º E 59 DO CP. ENTENDIMENTO. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500199-27.2019.8.26.0407, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/11/2020). Ainda: "Descabe, igualmente, pleitear aqui regime prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500128-92.2021.8.26.0559, Rel. Fátima Gomes, 9ª Câmara de direito Criminal, julgado em 31.03.2022).

Deixo de aplicar o § 4º do art. 33 da lei em tela, ante a quantidade e a variedade de entorpecentes, bem como ante o concurso de agentes, fatos a apontar maior periculosidade dos réus, indicando dedicarem-se à atividades criminosas, mesmo porque, não existe comprovação de atividade laborativa.

Neste sentido, o RHC nº 116.926, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/9/13, no qual se decidiu que: "a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010" (g.n.).

O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica dos acusados (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno LUCAS MATHEUS RIBEIRO DE SOUZA, R.G. n.º 75.013.726 e LUAN CARLOS MARTINS, R.G. n.º 58.131.020, cada um, a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por terem infringido os arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, combinados na forma do caput do art. 69 do Cód. Penal.

Não poderão os réus apelar desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do

feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento dos réus do convívio social, por garantia da ordem pública. Recomendem-se os réus no presídio onde se encontram, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflictivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação dos delinquentes.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, "a" e "b", do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO dos petrechos, porque utilizados como instrumentos do crime, bem como do dinheiro e do celular (fls. 23/25), pois obtidos em razão do comércio ilícito de drogas, conforme prova colhida. Para tanto, oficie-se ao FUNAD. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para que se proceda a destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova. Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C..

São José do Rio Preto, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA